

1500287-96.2022.8.26.0201

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Renata Lima Ribeiro Raia

Comarca: Garça

Foro: Foro de Garça

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2032429/2022 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 16939075 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO,
13/22/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2032429 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO GONÇALVES ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Garça

Foro de Garça

1ª Vara

Praça Dr. Martinho Funchal de Barros, 50, Garça-SP - cep 17400-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500287-96.2022.8.26.0201 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500287-96.2022.8.26.0201

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2032429/2022 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 16939075 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO,
13/22/201 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO, 2032429 - DEL.POL.ALVARO DE CARVALHO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO GONÇALVES NAKAGAWA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Lima Ribeiro Raia

Vistos.

FERNANDO GONÇALVES NAKAGAWA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, III, da Lei nº 11.343/2006, observado o disposto na Lei nº 8.072/1990, porque, no dia 6 de janeiro de 2022, por volta das 16 horas, no alojamento B, da ala de progressão, da Penitenciária "Valentim Alves da Silva", situada na Rodovia Mamede Barreto (SP-349), Km 36, na cidade de Álvaro de Carvalho, comarca de Garça, mantinha em depósito, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 55 (cinquenta e cinco) invólucros plásticos contendo maconha (85,39 gramas), tudo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Narra a denúncia que o réu cumpre pena privativa de liberdade na referida unidade prisional. Na data dos fatos, agentes penitenciários realizavam procedimento de revista geral na ala de progressão da unidade prisional e, no momento em que vistoriavam o alojamento B, localizaram na cama B-124, oculto em meio aos pertencentes do réu, os entorpecentes descritos, dos quais o réu informalmente assumiu a propriedade.

É da denúncia que as circunstâncias fáticas indicam que os entorpecentes se destinavam à comercialização, porque a quantidade encontrada é incompatível com a condição de usuário e estava em porções individuais prontas para venda dentro da penitenciária.

Auto de apreensão à pág. 9 e laudo às págs. 12/17.

Denúncia oferecida aos 10 de março de 2022 (págs. 28/29).

Folha e certidão de antecedentes às págs. 37/57.

O réu foi notificado (pág. 62) e apresentou defesa prévia (págs. 66/67).

Aos 30 de maio de 2022, recebida a denúncia e determinada a instrução (págs. 72/73). O réu foi citado (pág. 99).

Inquirida testemunha e interrogado o réu, passou-se às alegações finais. O Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da denúncia, fez observações sobre a prova colhida em audiência e considerações sobre a dosimetria da pena. Argumentou que a droga estava junto de carta e carteirinha de identificação do réu. Sustentou que o réu ostenta condenações e cumpre pena pelo delito de latrocínio, sendo reincidente, circunstância que deve ser considerada para a fixação da pena e do regime inicial de resgate. A Defesa propugnou pela absolvição, aduzindo, em síntese, que há incongruência entre as falas do réu e da testemunha, sobre quem teria encontrado a droga e convocado o réu a verificá-la. O réu disse que não foi a testemunha quem o chamou e constatou a droga, e sim o diretor da unidade prisional. Segundo disse o réu, ele não foi convidado a ingressar na cela para ver a droga, havendo falha procedimental. Em sede policial, o réu também negou a autoria, assim como negou ser usuário de droga. Alegou, ainda, que réu e testemunha disseram que o local era um alojamento, onde havia outros presos, aproximadamente noventa e cinco pessoas, das quais onze se envolveram em situações semelhantes à do acusado. Conforme sustentou, ainda que constatada a substância, a questão da autoria e da dinâmica é dúbia; há fortes indícios de que a droga foi plantada e de que não estava com ele no local. Alternativamente, em caso de condenação, argumentou que deve ser considerada a pequena quantidade de droga, menos de cem gramas em pequenos papелotes, sem qualquer evidência a demonstrar que essa seria a intenção do agente ao portar a droga. Que, não há prova de que o réu fez ou faça parte de facção criminosa, apesar de sua reincidência. Postulou a desclassificação do delito ou aplicação da causa especial de redução do § 4º do artigo 33 na terceira fase. Alegou que na primeira fase da dosimetria a pena deve ficar no mínimo legal devido às circunstâncias pessoais e judiciais, e, na segunda, se aplicada a reincidência, que o seja no mínimo legal (págs. 145/146).

É o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido condenatório é procedente.

Materialidade, autoria e o elemento subjetivo restaram comprovados pelo auto de apreensão (pág. 9), laudo (págs. 12/17) e prova oral.

De fato, no material apreendido foi detectada substância de uso proscrito no Brasil (Tetrahidrocannabinol - THC - págs. 12/17).

Já as circunstâncias da apreensão foram descritas pelo agente penitenciário que realizou o procedimento. Aludida testemunha descreveu que foram encontrados cinquenta e cinco invólucros nos pertences do réu. Mencionou que realizam revista nos pertences, observando se há cartas, carteirinha, levam o preso até a cama e perguntam se aquela cama é dele. Disse que, com a resposta afirmativa, falam para acompanhar a revista. Havia mais detentos na cela, todos foram colocados para fora. Afirmou que o réu foi questionado sobre a droga e falou que era dele. Referiu que a droga estava em um tipo de picuá, que o preso fez com lençol e onde estavam os pertences, inclusive cartas de familiares. Afirmou que todos os presos são chamados para identificar a cama. Disse que há scanner corporal para revista quando o preso entra, mas que o equipamento nem sempre detecta, a depender do volume, sendo difícil identificar se o pedaço é pequeno. Disse não se recordar da posição da cama do réu. Confirmou ter sido quem encontrou a droga e chamou o réu para identificar se a cama era dele. Descreveu que os presos colocam o picuá em uma escadinha que serve para guardar coisas pessoais na cama de cada um. Disse, por fim, que na ocasião o réu afirmou ser dele a droga e não falou o que ia fazer com ela (págs. 145/146).

Interrogado, o réu disse que está preso por 157, § 3º, e que já respondeu a outros processos há muitos anos atrás. Disse que residia em São Caetano do Sul, ser solteiro e ter seis filhos, e que trabalhava com o pai, na retífica dele. Em relação ao crime descrito na denúncia, disse que tinha voltado da saída temporária de dezembro, apresentando-se no dia 3. Foi recebido pelo senhor Nilton, que os levou à subportaria, onde passaram por detector de metal e scanner. Seguiram para a ala, os guardas mandaram que pegassem os pertences e entrassem para quarentena na ala B. Lá na contagem respondia pelo número de cama, a 124-B. No dia dos fatos, houve contagem antecipada, às 16h. Foi um dos primeiros a sair. O agente penitenciário trancou a porta quando o último saiu. Mandaram que se sentassem com a mão na cabeça. Entraram para fazer vistoria e foram chamando. Acharam uma carta de sua mãe, e o chamaram pela carta e o algemaram. Disse que poderia falar que a droga era para uso próprio, mas não era sua e não faz uso. Sua cama ficava no canto da parede, nos fundos do alojamento. Quando houve a chamada para vistoria, havia aproximadamente noventa e seis pessoas no alojamento, as quais estavam retornando. Foi um dos primeiros a sair da cela. Há duas câmeras de filmagem na ala de progressão e nelas se pode ver que foi um dos primeiros a sair e esperou o último. Quando estava fora da cela, o Diretor Geral, senhor Leonardo, foi quem o chamou pela matrícula e daí foi algemado e levado para a inclusão. Nesse dia, mais onze presos foram autuados do mesmo jeito. De alguns pegaram carteira de trabalho, de alguns pegaram carta, como foi seu caso. Não é usuário de droga. Mencionou que há mais de vinte anos teve passagem por porte de entorpecente, desde então passou por clínicas e deixou o vício (págs. 145/146).

Transposta a instrução processual, nota-se que o réu negou a prática delitiva descrita na denúncia. Essa negativa, contudo, destoa do conjunto probatório.

Com efeito, o agente penitenciário Nilton descreveu com ocorreu a localização da droga nos pertences do réu. Asseverou que durante a revista tomam o cuidado de observar se há cartas, carteirinha, isto é, itens pessoais que propiciam a identificação. Ademais, afirmou que instam o preso a indicar a cama correspondente. Apontou particularidade que contribuiu para a identificação do agente infrator, referindo que os presos colocam o picuá em uma escadinha usada para guardar coisas pessoais na cama de cada um. Também mencionou que o réu afirmou ser dele a droga e não falou o que ia fazer com ela (págs. 145/146).

Vale sobrelevar que nada há nos autos a infirmar a palavra da testemunha. Nesse contexto, seria um contrassenso o Estado desacreditar a palavra do agente que atuou no cumprimento do dever e nos limites da legalidade. A esse respeito, transcrevo trecho de elucidativo acórdão:

"No caso vertente, inexistiu motivo para se repudiar a firme e segura palavra dos agentes públicos inquiridos, pois nada de concreto se demonstrou que pudesse tisonar de parcialidade o depoimento deles, prestado sob o compromisso legal, não sendo crível que fossem levianamente imputar um crime de tal gravidade a pessoa inocente, ainda mais se valendo desnecessariamente de certa quantidade e variedade de drogas, mesmo porque isso nenhum proveito lhes traria. A propósito, cabe lembrar prevalecer a presunção de que os agentes públicos agem no cumprimento do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio a palavra deles quando, como no caso, noticiam em Juízo suas atividades no combate e repressão à criminalidade (...) Além disso, as circunstâncias da prisão, ocorrida durante "blitz" realizada na cela em que habitava o réu, ocasião em que encontrados sobre a cama dele tóxicos, "chips" de celular e caderno com anotações típicas de contabilidade de tráfico (laudo pericial - fls. 76/93) em meio a pertences do acusado e junto com carta e comprovante de depósito bancário que lhe pertenciam, aliadas à quantidade, variedade e forma de acondicionamento dos entorpecentes, em porções prontas para entrega ao consumo de terceiros, não deixaram dúvida quanto a lhe pertencer o tóxico e se destinar ele ao insidioso comércio." (TJSP Apelação Criminal nº 1500218-84.2020.8.26.0411, 1ª Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Mário Devienne Ferraz, j. 22.8.2022)

A propósito, o próprio réu confirmou que respondia pelo número de cama na contagem - a 124-B -, exatamente aquela indicada no comunicado de evento 023/2022 (pág. 8). Além disso, mencionou que a contagem naquele dia foi antecipada, de modo a evidenciar haver sido surpreendido pela atuação dos agentes públicos.

Especificamente em relação às câmeras existentes na ala de progressão, as quais, segundo o réu, registraram que ele foi um dos primeiros a sair e esperou o último, isso não elide a prova da materialidade e autoria antes destacada. Ainda a esse respeito, gize-se que o diretor da unidade prisional informou não ter sido constatada situação atípica que reclamasse o armazenamento de imagens (pág. 91).

Outrossim, o modo como ocorreu a apreensão do entorpecente colide com a ilação de que outro preso poderia ter plantado a droga. Isso porque iminentes à atuação dos agentes as cautelas para evitar esse tipo de evento. Repita-se que o réu mencionou que a revista ocorreu antes do horário e teve que esperar o último preso deixar a cela. Sobre tais peculiaridades, o julgado supramencionado, referente a caso semelhante, assim discorreu:

"Por outro lado, não prospera a alegação da defesa, no sentido de que algum detento desconhecido teria jogado os tóxicos na cama do apelante, porque, ao que é dado concluir dos depoimentos dos agentes públicos, a "blitz" foi realizada de surpresa e com toda cautela para evitar uma ocorrência dessa natureza."

O delito do artigo 33, caput, da Lei de Drogas é de ação múltipla, conteúdo variado, que se consuma com a prática de uma das condutas descritas no tipo penal. No caso, o réu mantinha em depósito, no interior de unidade prisional, para fins de fornecimento e entrega a consumo de terceiros, 55 (cinquenta e cinco) invólucros plásticos contendo maconha, de modo que não há se falar em desclassificação.

Nesse contexto, aliás, também restou demonstrada a majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de regência, porquanto o delito foi praticado no interior de estabelecimento prisional - Penitenciária Valentim Alves da Silva.

Presentes, pois, os pressupostos para a responsabilização penal, passa-se à dosimetria da pena com atenção para as regras previstas no artigo 68 do Código Penal.

Na primeira fase, observo que há circunstâncias judiciais desfavoráveis, uma vez que o réu ostenta antecedentes desabonadores (autos 1014213-73.1996.8.26.0506 e

0006844-33.1994.8.26.0565 - págs. 37/57) e incorreu no crime retratado nos autos quando retornava de saída temporária, benefício que pressupõe bom comportamento, de modo que procedo ao aumento de 1/6 à pena, resultando 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. No que toca aos antecedentes, aponto a tese firmada no Tema 150 em sede de repercussão geral, consoante a qual não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no artigo 64, I, do Código Penal.

Na segunda fase, agravo de 1/6 a pena em decorrência da reincidência (autos 0000802-40.2009.8.26.0565, com final de pena previsto para 2032, conforme folha de antecedentes aferida nos moldes da Súmula 636 do STJ - págs. 37/57), perfazendo a pena intermediária de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira e última fase, por força da causa de aumento do artigo 40, inciso III, da Lei nº. 11.343/2006, aumento a pena de 1/6, resultando 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa. Ausentes elementos informadores suficientes sobre a situação financeira do réu, arbitro o valor de cada dia-multa no mínimo legal. Anoto que não se cogita aplicar o redutor do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/2006 diante da reincidência que, específica ou não, não se compatibiliza com a causa especial de diminuição.

Aplico o regime inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos das regras de individualização da reprimenda, conforme dispõe o artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal.

Não preenchidos os requisitos para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou sursis, haja vista o tempo de pena, maus antecedentes e reincidência (Código Penal, artigos 44 e 77).

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido acusatório e condeno FERNANDO GONÇALVES NAKAGAWA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/2006, a cumprir pena de 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", e § 3º, do Código Penal, além do pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, conforme artigo 43 da Lei 11.343/2006, a ser atualizado.

O réu está respondendo solto a este processo (preso por outro) e assim poderá interpor eventual recurso.

Incinere-se quantidade de substância entorpecente que tenha remanescido, com atenção para o artigo 72 da Lei nº 11.343/2006 e o artigo 525 das Normas de Serviço.

Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário ao cumprimento da pena, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD, oficie-se ao TRE/SP para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal, arquivando-se os autos oportunamente com as comunicações e anotações de praxe.

Deixo de fixar a verba mínima indenizatória do artigo 387, IV, do CPP, uma vez que não houve pedido a propiciar o contraditório.

Custas pelo réu, conforme artigo 804 do Código de Processo Penal e artigo 4º, § 9º, da Lei nº 11.608/2003, sobrestada a cobrança em caso de gratuidade

Dispensado o registro da sentença, conforme artigo 72, § 6º, das Normas de Serviço

da Corregedoria Geral da Justiça.

Publique-se e intímese.

Garça, 12 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA